

1503076-68.2021.8.26.0180

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Consta ainda que no dia 10 de junho de 2021, por volta de 17h, na Avenida Rafael Orichio Neto, nº 645, Centro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA, trazia consigo, para fins de tráfico, 18 (dezoito) porções de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

1ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503076-68.2021.8.26.0180 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503076-68.2021.8.26.0180

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157585/2021 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 18431827 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 938/21/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2157585 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROSELI JOSE FERNANDES COUTINHO

Vistos.

RICARDO DOS REIS e TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de junho de 2021, em horário não apurado, na Avenida Rafael Orichio Neto, nº 645, Centro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, os acusados associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Consta ainda que no dia 10 de junho de 2021, por volta de 17h, na Avenida Rafael Orichio Neto, nº 645, Centro, Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA, trazia consigo, para fins de tráfico, 18 (dezoito)

porções de cocaína, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 46/48 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 49/50), tendo RICARDO DOS REIS concorrido de qualquer forma para a prática do crime.

Consta também que nas mesmas condições de tempo e lugar, RICARDO DOS REIS, guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 61g (sessenta e um gramas), droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 46/48 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 49/50), tendo TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA concorrido de qualquer forma para a prática do crime.

Consta por fim que nas mesmas condições de tempo e local, TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA, vendeu a Matheus Donizeti Ribeiro de Macedo 01 (uma) porção de cocaína, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 46/48 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 49/50), tendo RICARDO DOS REIS concorrido de qualquer forma para a prática do crime.

Laudo Pericial às fls. 155/157.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 215/218).

A ré Tamara foi regularmente notificada (fl. 154), apresentando defesa prévia às fls. 162/176.

O réu Ricardo foi regularmente notificado (fl. 158), apresentando defesa prévia às fls. 201/207.

No curso da instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma testemunha arroladas pela defesa de Tamara, seguindo-se do interrogatório dos réus, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, requerendo a procedência da ação penal e condenação dos réus nos termos do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos dispositivos da Lei nº 11.343/06. Os Policiais confirmaram integralmente versão apresentada em solo policial. Ressaltou versão contraditória dos réus, Tamara admitiu a venda da droga ao Matheus, por R\$ 10,00, justificando que apenas vendeu para que para o marido que estava no banho. Já Ricardo disse que é proprietário de 05 porções e que deixou a droga com a esposa, estranha versão. Negou mercancia e tentou atribuir ato unilateral da droga a esposa Tamara. Versões colidentes de delações recíprocas. Tratando-se de atos praticados por cônjuges e a narrativa de Matheus pela segunda vez adquiriu drogas de Tamara (fl. 11), patente estabilidade para associação para o tráfico. Quanto à reprimenda, na primeira fase, requereu que sejam considerados os maus antecedentes de Ricardo. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase ausentes causas aumento ou diminuição Tamara é primária e não ostenta maus antecedentes, na segunda fase atenuante da confissão, contudo não pode levar a pena a quem do mínimo legal. Considerada confissão parece razoável redutor do §4º da Lei de drogas. O regime de cumprimento não seja o fechado.

A defesa de Tamara requereu a absolvição da acusada de todos os delitos descritos na denúncia, eis que os entorpecentes não lhe pertenciam, eram de Ricardo. Tamara só efetuou a venda pelo fato de Ricardo estar no banheiro naquele momento, apenas o fez porque era obrigada pelo seu convivente, visto que ele não podia perder o dinheiro, pois tinha que comprar gás, além de sofrer violência psicológica por parte de Ricardo. Alegou se tratar de um ato isolado e praticado sob forte coação moral. Presentes atenuantes do art. 65, alíneas do "c" e "d" do CP (confissão e coação moral resistível), presente, ainda, §4º do art. 33 da Lei 11.343/05.

Requereu absolvição por excludente de culpabilidade (art. 22, caput, coação irresistível) para absolvição. Bem como absolvição do art. 35 por falta de provas. Subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, com aplicação do regime aberto. A defesa de Ricardo, por sua vez, requereu que seja considerada sua a confissão espontânea, que confirmou a propriedade de toda a droga encontrada, bem como

afirmou que destinavam ao comércio. O acusado estava sem rendimentos financeiros para garantir-lhe o sustento e em uma atitude impensada adquiriu a droga no intuito de comercializar. Lado outro, requereu a absolvição do acusado quanto ao crime de associação ao tráfico, ante a inexistência de prova apta a caracterizar o vínculo subjetivo de caráter estável e permanente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes. Quanto à reprimenda, em segunda fase, que seja considerada a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Em terceira fase, que seja beneficiado com a redução de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, com substituição por restritivas de direitos. Absolvição do artigo 35, porque não esta provada associação.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 46/48), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 49/50), pelos receituários médicos (fls. 56, 57 e 58), pelas guias de depósito judicial (fls. 112 e 113), pelo laudo pericial (fls. 155/157), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, é certa.

Em solo policial (fl. 13), a acusada Tamara utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e pretende se manifestar apenas em juízo.

Em juízo disse negou ter vendido drogas. Disse que não tinha conhecimento do dinheiro e da porção que foi encontrada. Ele era usuário. Não sabe quanto tinha nessa caixa de fosforo. O policial chegou gritando e disse que se queria acompanhar o marido até a delegacia, por isso estava sendo detido. Disse que marido falou para entregar a droga para o rapaz, inicialmente negou dizendo que não mexia com isso, mas ele insistiu. Disse que ficou com medo e acabou entregando. Entregou a droga e recebeu os R\$ 10,00. Quando o marido saiu do banho os policiais entraram na casa. As porções de droga estavam dentro da caixa de fósforos, que estavam no inteiro do bolso da depoente. Negou a existência de outro usuário, não tem rota de fuga como afirmado pelos policiais. Na residência estava a depoente, o marido e um conhecido dele, mas os policiais levaram apenas os dois. Na delegacia o marido disse que a droga era dele. Esse dinheiro só ficou sabendo da existência quando chegou à delegacia. Esse dinheiro não lhes pertencia. Não sabia que Ricardo traficava. Só ficou sando quando o rapaz chegou pra comprar drogas. Não conhecia o Matheus, sabia que estava entregando drogas, e recebeu R\$ 10,00, por ordem do marido. Ele não entregou porque estava no banho. Disse que foi a primeira vez que ele pediu algo assim.

Em solo policial (fl. 14), o acusado Ricardo utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e pretende se manifestar apenas em juízo.

Em juízo disse que acerca do que os policiais disseram, que alguém fugiu pulando o muro, isso é impossível, porque a casa fica nos fundos e tem casa de todos os lados. Quanto aos fatos, disse que há algum tempo era usuário de crack e a Tamara me tirou dessa droga. Porém, caiu na besteira de usar cocaína. Foram encontradas porções com a Tamara, mas desconheço 18 capsulas de cocaína. Não tem como caber isso numa caixa de fósforos. Não tinha dinheiro pra comprar tudo isso. Desconhece alegação de que a casa era conhecida como ponto de trafico. A droga que foi encontrada no bolso da Tamara, são 05 capsulas de cocaína, estava no banho. Disse que estava sentado a mesa da casa quando os policiais chegaram. Foram direto no bolso dela dizendo que ela estava presa. Os policiais disseram que o depoente também. Admitiu que apenas 5 cápsulas lhes pertenciam, destinavam para o uso pessoal. Eles encontraram cerca de R\$ 380,00 dentro de uma mochila do cunhado da Tamara. Ficou bravo com ela porque não sabia desse dinheiro. Essas outras drogas não sabia da existência, ficou bravo com ela porque havia droga sem o depoente saber. Não sabe se foram plantadas ou se realmente estavam lá. Discutiu com a Tamara porque não era pra vender a droga ao usuário. Entregou as drogas para Tamara as 05 foi para o banho. Não pediu pra ela vender as drogas. Não tinha dinheiro para comprar mais. Não soube dizer porque falou para ela não vender drogas, já que não costumavam vender.

Em solo policial (fls. 07/08), o Policial Militar Wellington Davanco Bezerra disse que estava de serviço com seu companheiro de farda SD PM Leme, em patrulhamento pela Rua Rafael Orichio Neto, momento que avistaram Matheus Donizetti Ribeiro de Macedo saindo correndo da residência nº 645, indo em direção à casa dele, na rua Arnaldo Machado Florence, nº 189. Que na iminência de adentrar no imóvel, o abordaram. Que após busca pessoal, localizaram com Matheus um pino com substância semelhante à "cocaína". Indagado, este informou que tinha acabado de comprar o entorpecente na residência de onde havia saído, na Rua Rafael Orichio Neto, 645, da pessoa de Tamara, pelo valor de R\$ 10,00. Matheus disse ainda que ela havia acondicionado drogas dentro de uma caixa de fósforo. Que diante de tal informação, dirigiram-se até o referido imóvel e na porta da casa, avistaram um indivíduo, o qual não foi identificado, jogando um pino no chão e entrando em disparada naquela casa, pulando os muros vizinhos, não sendo alcançado. Que diante do ocorrido, pegaram o microtubo, entraram no imóvel e lá se depararam com o casal Tamara Rafaela Lopes da Silva e Ricardo dos Reis. Que após abordarem ambos, perceberam um volume no bolso da calça da indiciada e, questionada, Tamara entregou a equipe uma caixa de fósforo contendo dezoito pinos com substância semelhante à "cocaína", idênticos aquele localizado com Matheus, além de R\$ 10,00 em dinheiro, objetos estes que estavam em seu bolso. Indagada, Tamara disse que a droga pertencia a seu marido e que seria destinada a venda, e que o valor em dinheiro era fruto da venda que acabara de fazer para Matheus. Que a indiciada disse ainda que quem realizou a referida mercancia havia sido ela, pelo fato de Ricardo estar no banheiro naquele momento. Indagado separadamente, Ricardo assumiu a propriedade das drogas e entregou a equipe uma peneira, que alegou utilizar para a preparação das drogas, uma porção grande análoga à "cocaína", R\$ 311,00 em dinheiro, um aparelho de telefone celular, além de vários pinos vazios, sendo que alguns deles possuem resquícios de substância branca, que aparentam ser "cocaína". Relata ainda que Ademilson Aparecido Soares também estava na casa, mas nada de ilícito localizaram com ele. Diante dos fatos, deram voz em prisão ao casal Tamara Rafael Lopes da Silva e Ricardo dos Reis e conduziram todos os envolvidos até a Unidade Policial. Deseja constar que foi utilizado o uso de algemas no casal, pelo receio de fuga e pelo fato dos dois aparentarem bastante nervosismo. Por fim, cientificaram todos os conduzidos acerca de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecerem em silêncio, bem como acrescenta que contra o casal Tamara e Ricardo, pesam diversos informes de que praticam o tráfico há bastante tempo.

Em juízo disse que na data dos fatos estava em patrulhamento na companhia do PM Leme, que avistaram Matheus, usuários de drogas, que ao avistar a viatura começou a caminhar rapidamente de forma suspeita. Foi abordado, com o qual encontraram um pino de cocaína. Ele afirmou que tinha acabado de adquirir esse pino na casa da Tamara, residência já conhecida dos meios por tráfico de drogas. Voltaram para frente da casa e avistaram outro indivíduo que saiu correndo para interior da residência, não foi possível deter porque pulou o muro. Avistaram Tamara e Ricardo no interior da residência, os dois foram abordados. No bolso da Tamara avistaram um grande volume, que ela acabou tirando do interior deste bolso uma caixa de fósforos. No interior da caixa havia diversas porções de cocaína. Ela assumiu que estava junto com o amasio Ricardo realizando tráfico de drogas porque estavam precisando de dinheiro. Tinha denúncia de que os dois estavam realizando tráfico. Em solo policial (fls. 09/10), o Policial Militar Ewerton Luiz Leme prestou depoimento idêntico ao do PM Wellington Davanco Bezerra, uma vez que participou de todas as diligências.

Em juízo disse estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um conhecido usuário, que ao avistar a viatura comportou-se de forma suspeita e foi abordado. Indagado, ele afirmou eu tinha acabado de adquirir uma porção de cocaína da Tamara. O local era próximo e retornaram a frente da residência dela. Chegando próximo à casa da Tamara avistaram um sujeito no portão da casa dela, que ao avistar a equipe dispensou um pino de cocaína ao solo e entrou correndo pra dentro. Entraram para ver se o encontrava, ele pulou o muro. Avistaram Tamara e Ricardo na cozinha. No bolso da Tamara havia certo relevo, um volume anormal no bolso, que ela informou que era uma caixa de fósforos onde havia uns pinos de cocaína. Encontraram

ainda cerca de R\$ 300,00. Indagado acerca da droga, ele informaram que estava traficando porque estavam sem dinheiro. Eles foram encaminhados ao DP. Localizaram um pacote branco de uma substancia que aparentava ser cocaína, mas não tinham certeza. O dinheiro estava na residência da Tamara disse que era proveniente do trafico. Havia várias denúncias indicando que os dois estavam traficando. Não se recorda de ter apreendido uma peneira.

Em solo policial (fl. 11) a testemunha Matheus Donizeti Ribeiro de Macedo disse que se dirigiu até a residência do casal Ricardo e Tamara, e comprou com Tamara um pino com cocaína, pelo valor de R\$ 10,00. Informa que em seguida, saiu correndo da casa da indiciada, pois estava chovendo, e antes de chegar em sua residência, foi abordado pelos Policiais Militares. Que então entregou o entorpecente para os policiais, e confirmou á eles que havia acabado de comprar de Tamara. Indagado, relata que esta foi a segunda vez que compra entorpecente na residência dos indiciados, sendo que da primeira vez também adquiriu de Tamara. Questionado, informa que é usuário de cocaína há muitos anos, porém não está envolvido com o tráfico de drogas.

Em solo policial (fl. 12) a testemunha Ademilson Aparecido Soares disse que é amigo do casal Tamara e Ricardo. Que está pernoitando na residência dos dois há duas semanas. Que nesta data, no momento da entrada dos Policiais Militares no imóvel, alega que estava dormindo, "eu tava dormindo com a cabeça coberta. Eu só escutei os PMS falando 'perdeu, perdeu!'" (sic). Inquirido, alega que nada viu da ocorrência, haja vista que estava dormindo. Questionado, nega que tenha conhecimento de que o casal pratica o tráfico de drogas, "eu não sabia. Fiquei sabendo hoje" (sic).

Em juízo a informante Tábata Richelle Lopes da Silva Carleti disse ser irmã da ré Tamara, que leal nunca se envolveu com drogas, com crimes. Que ela se afastou da família após o envolvimento com o réu, que a impede de visitar os familiares.

Reafirmou que ela é uma pessoa trabalhadora que sempre ajudou os pais.

Quanto ao artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06:

Os depoimentos dos Policiais Militares merecem toda credibilidade, foram firmes e confirmaram que durante um patrulhamento avistaram Matheus Donizeti Ribeiro de Macedo saindo correndo de uma casa, motivo pelo qual foi abordado pelos policiais e em busca pessoal localizaram com ele um pino de cocaína. Matheus relatou que comprou o entorpecente na casa que havia saído, da pessoa de Tamara, pelo valor de R\$ 10,00, bem como informou que a acusada havia acondicionado drogas dentro de uma caixa de fósforos. Diante das informações, dirigiram-se até a referida residência e logo na porta da casa puderam ver um indivíduo dispensando um pino ao solo e entrando em disparada na residência, pulando os muros vizinhos, entretanto não foi alcançado. O microtubo foi apreendido pelos policiais, que em seguida adentraram ao imóvel e se depararam com os acusados. Foram apreendidas drogas que estravam no bolso da calça de Tamara, acopladas em uma caixa de fósforos, além de dinheiro. Questionada Tamara informou que as drogas pertenciam a Ricardo e que eram destinadas a venda, e o valor em dinheiro era fruto da venda que acabara de fazer para Matheus. Ricardo assumiu a propriedade das drogas, entregou para os policiais uma peneira que utilizava para a preparação dos entorpecentes, uma porção grande de cocaína, R\$ 311,00 em dinheiro, um aparelho de telefone celular e vários pinos vazios, alguns deles com resquícios de substância entorpecente.

Foi apreendida 01 (uma) porção (pino) de cocaína com Matheus, que foi adquirido por ele na residência dos acusados. Com Tamara foi encontrada uma caixa de fósforos contendo 18 (dezoito) porções (pinos) de cocaína, idênticos ao localizado com Matheus, além de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e outros objetos que estavam em seu bolso. Ricardo confirmou aos policiais a propriedade das drogas e entregou 01 (uma) porção grande de cocaína (que posteriormente descobriu-se não se tratar de cocaína), uma peneira que era utilizada na preparação das drogas, R\$ 311,00 (trezentos e onze reais) em espécie, um aparelho celular e vários "pinos" vazios, um dos quais continha resquícios de drogas.

Em solo policial, a testemunha Matheus confirmou que se dirigiu até a residência dos acusados e comprou com Tamara um pino de cocaína, pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais). Confirmou ainda que foi a segunda vez que comprou entorpecentes na

residência dos acusados, sendo certo que na primeira vez também foi Tamara quem efetuou a venda.

Não obstante em relação à parte das porções apreendidas não tenha se confirmado a natureza entorpecente, eis que a porção maior não se confirmou se tratar de cocaína, conforme laudo juntado aos autos. Há provas para condenação, pois foram apreendidas 18 porções de cocaína, cuja natureza foi confirmada pelo exame pericial.

Em juízo, os policiais narraram de forma harmônica os fatos, confirmando tudo quanto dito em solo policial. Reafirmaram a delação feita pelo usuário Matheus, bem como a apreensão das drogas na posse de Tamara e Ricardo.

Os réus em juízo confessaram parcialmente os fatos e prestaram depoimentos incoerentes e fatos que se contrapõem. A ré Tamara admitiu ter vendido a droga para Matheus a mando de Ricardo, que estava no banho. Embora a defesa tenha alegado que ela agiu sob coação, dos relatos da ré Tamara não se extrai qualquer ameaça capaz de causar coação, a que tudo indica ela vendeu, segundo sua versão, para atender o pedido do marido que estava impossibilitado no momento.

Todavia, não se pode desconsiderar que o usuário afirmou ter adquirido droga na casa de Tamara, comprando diretamente dela, o que sugere ser ela mais conhecida no meio que o próprio companheiro.

Além disso, mesmo depois de vender a porção de cocaína, permaneceu na posse do dinheiro e das demais porções e cocaína, o que demonstra que continuaria na empreitada criminoso.

Já na versão de Ricardo admite apenas a posse de cinco porções de cocaína, que segundo ele chegou a casa e entregou para a companheira, advertindo-a para não vender porque não tinha mais dinheiro para comprar mais. Tal versão é ilógica, pois se o casal não vendia drogas, porque ele a advertiria para não vender. Por óbvio, essa advertência só teria sentido se o casal estivesse praticando o tráfico. Em outras palavras, ele admitiu - sem querer - que a casa era frequentada por usuários em virtude da venda de drogas.

Quanto aos valores apreendidos Ricardo admite que foram apreendidos na bolsa da companheira, enquanto a ré Tamara alega a inexistência de dinheiro no local. Portanto, mais uma vez se contradizem quanto a fatos, o que corrobora para condenação, pois pretendem ambos se livrarem do dinheiro que comprova ser fruto do tráfico, eis que nenhum dos réus tem justificativa lícita para a posse desses valores.

A caracterização da traficância restou evidenciada, não se mostrando necessária a efetiva visualização da venda, pois o tipo penal admite outras condutas além de vender, dentre elas estão "trazer consigo", "guardar" e "transportar". Contudo, no caso dos autos, a prisão ocorreu logo após a efetiva venda praticada pelos réus.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente (RT 776/663)".

Não bastassem as drogas apreendidas, podemos confirmar a traficância através da própria confissão parcial da ré Tamara em juízo, oportunidade que confessou ter vendido drogas apedido do companheiro, confessando e delatando o correu.

Assim, considerando as circunstâncias em que os réus foram presos, não se tem

dúvidas de que estavam traficando, impondo-se a aplicação das penas previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto às teses subsidiárias invocadas pela ré Tamara, porque não demonstrada qualquer tipo de coação moral, resistível ou irresistível, deve ser afastada a pretensão de absolvição por excludente de culpabilidade, bem como a atenuante da coação resistível (art. 65, I, alínea "c"). Deve ser reconhecida a atenuante da confissão quanto ao crime de tráfico.

Quanto ao réu Ricardo, deve ser afastada a atenuante da confissão, eis que admitiu apenas a posse no intuito de obter a desclassificação do delito para a figura do artigo 28 da Lei de drogas, portanto, inadmissível o reconhecimento da atenuante.

Quanto ao artigo 35, caput, da Lei Federal n.º 11.343/06:

A associação para o tráfico, conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas não restou provada nos autos, pois não se demonstrou a existência do animus associativo, com caráter de habitualidade, estabilidade e organização, mas sim mera convergência ocasional de condutas, não caracterizando a associação.

Dos depoimentos prestados em juízo, não foi possível extrair a comprovação de um verdadeiro liame subjetivo entre os réus para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

Muito embora os policiais tenham referido a existência de denúncias prévias, esses relatos não se confirmaram de forma contundente, eis que o usuário que afirmou ter adquirido mais uma vez drogas no local não foi encontrado para ser ouvido em juízo.

Portanto, não há o que se falar em associação criminosa. Não há qualquer evidência concreta de que praticam tráfico de entorpecentes juntos, embora haja indícios nesse sentido, não há provas para corroborar com essa afirmação e que possam ser utilizadas para fins de se comprovar alguma estabilidade que se exige para a associação.

A parcial procedência da ação penal é medida de rigor, pois o réu deverá ser absolvido da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

A quantidade e diversidade de droga são critérios que podem ser utilizados tanto elevação da pena base, por aplicação dos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, quanto para dosar a diminuição de pena do §4º, do artigo 33 da lei de Drogas, em razão de ausência de critérios legais específicos para se dosar a maior ou menor de diminuição. Em qualquer circunstância não será possível a utilização dos mesmos critérios na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que a causa de diminuição de pena é critério preponderante sobre as circunstanciais judiciais, a quantidade e diversidade de entorpecentes serão consideradas na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto à acusada Tamara Rafaela Lopes da Silva:

Na primeira fase, a pena base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada no mínimo legal, a ré é tecnicamente primária, portanto nesta fase, não há elementos nos autos para se aferir possuir Maus antecedentes, assim fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 43 da Lei 11.343/06).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e não verifico atenuantes nem agravantes, mantendo a pena no patamar anterior, porque já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, da fixação da pena verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Tal causa de diminuição incide porque o réu era primário, possuía bons antecedentes, não havendo indícios de que se dedicava anteriormente aos fatos, a atividades ilícitas ou integrava organização criminosa. A fração da redução não deve ser a máxima em razão da razoável pequena quantidade de droga encontradas. Reduzo, pois, sua pena em 2/3, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo mais circunstâncias a considerar, torno a pena definitiva aplicada.

Em virtude da nova redação do artigo 112, § 5º da Lei de Execuções Penais, que exclui a hipótese dos autos da condição de crime hediondo ou equiparado o tráfico com a causa de diminuição do § 4º da Lei de Drogas, o regime de pena seguirá os parâmetros do Código Penal. E, considerando a primariedade do réu e a pena em concreto aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser aberto.

Presentes requisitos legais, substituo a pena por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena imposta, e pagamento de prestação pecuniária em valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, em favor de entidade beneficente indicada pelo juízo da execução.

Quanto ao acusado Ricardo dos Reis:

Na primeira fase, a pena base, seguindo as diretrizes do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, deve ser fixada acima do mínimo legal, o réu possui duas condenações transitadas em julgado, que não poderão ser consideradas parra fins de reincidência (fls. 70/72), assim, serão consideradas nesta fase como maus antecedentes, com acréscimo de 1/6, sendo assim, a pena-base será fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 43 da Lei 11.343/06).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, motivo pelo qual a pena de ser mantida no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase ausente causa de aumento ou de diminuição, pois os maus antecedentes justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Não havendo mais circunstâncias a considerar, torno a pena definitiva aplicada.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, (redação conforme Lei 11.464/2007). O crime em concreto praticado pelos réus é deveras grave e, por isso mesmo, nem guardam compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Salles Abreu – 04/10/2011).

E ainda:

PENA – Restritivas de direitos – Tráfico de entorpecentes – Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) – Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 – Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 17/08/2006 – V.U.).

PENA – Restritivas de direitos – Réu condenado por tráfico de entorpecentes – Substituição da reprimenda privativa de liberdade – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 27/09/2006 – V.U.).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: (i) CONDENAR a ré TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA, RG: 28.928.205, nascida em 04/07/1984, natural de Espírito Santo do Pinhal – SP, filha de Benedito Lopes da Silva e Silvia Regina Mói da Silva, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com as substituições supra, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal; (ii) CONDENAR o réu RICARDO DOS REIS, RG: 46.854.719, nascido em 02/02/1983, natural de Espírito Santo do Pinhal – SP, filho de Dalva dos Reis, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem substituições, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; e para (iii) ABSOLVER os réus TAMARA RAFAELA LOPES DA SILVA e RICARDO DOS REIS da imputação do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

O valor da pena pecuniária foi fixado no mínimo legal.

Em relação ao réu Ricardo, subsistindo os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade que fundamentaram a decretação da prisão preventiva dos réus, em especial a ordem pública, o risco a instrução processual e possibilidade de se furto a aplicação da lei penal, entendo que os réus deverão permanecer preso cautelarmente.

Considerando o regime prisional e o montante de pena imposta à ré Tamara, reconheço-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Reconhecido o tráfico, de rigor o decreto de perda dos valores apreendidos em favor da União.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, as expensas dos condenados. Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados e oficie-se à SENAD, nos termos do art. 63, §4º da lei de 11.343/2006.

P.I.

Espirito Santo do Pinhal, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA